

1504275-83.2018.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... ILEGAL. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena-base se instâncias de origem apontam motivos concretos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504275-83.2018.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1504275-83.2018.8.26.0228

Controle nº 68/19

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

EDER MATEUS GOMES MOREIRA e outros

Aos 13/09/22, às 16 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu EDER MATEUS GOMES MOREIRA (preso na penitenciária de Guarulhos II) e a sua defensora, Dra. Virgínia S. R. Caldas Catelan, defensora pública, YGOR ALEXANDRE JAGER MESSIAS (preso na penitenciária de Tupi Paulista) e a sua defensora, Dra. Letícia Silva da Costa - OAB/SP 382178, e o réu HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA BUENO e o seu defensor, Dr. Vilmar Francisco Silva Melo - OAB/SP 262172. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, os réus foram interrogados. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: Os réus YGOR ALEXANDRE JAGER MESSIAS, HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA BUENO e EDER MATEUS GOMES MOREIRA estão sendo processados como incurso nas penas do 7, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes, pelos fatos narrados na denúncia (fls. 349/352). A denúncia foi recebida a fl. 353 (09/12/2019). O processo transcorreu de forma regular, sendo os réus regularmente citados (fls. 364, 367 e 393) e apresentado defesa prévia (fls. 375, 386 e 401/408), e nesta data encerrou-se a instrução probatória. É a síntese do necessário. O pedido formulado

na presente ação penal merece ser julgado procedente porquanto a prova carreada aos autos comprovou que em no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 03 horas e 20 minutos, Rua Pedro nº 546, Vila Albertina, neste Município e Comarca, YGOR, HUGO e EDER, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Ademir Borges de Freitas e Dulce Baird de Freitas, subtraíram, para si, um porta-joias contendo seis colares, uma pulseira e dois pingentes, de propriedade de Dulce, uma aliança, um anel de formatura, oito anéis, quatro brincos, duas correntes, uma caixa de som JBS, um Iphone, um Ipad, um relógio de pulso e R\$ 300,00 em dinheiro, de propriedade das vítimas. Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados e seus comparsas decidiram realizar um roubo. Visando perpetrar seu intento, dirigiram-se ao local dos fatos, onde adentraram na residência das vítimas, pulando o muro do imóvel. Em seguida, dominaram Dulce e a jogaram ao chão, instante em que gritou por seu marido. Ademir, por seu turno, acordou com os gritos e foi até a sua esposa, sendo também dominado pelos roubadores. Um dos autores do crime cobriu o rosto de Dulce com a mão, apontou uma arma de fogo contra sua cabeça e a ameaçou de morte, perguntando sobre a localização de um cofre contendo dinheiro. Ademir, por seu turno, foi golpeado no peito e mantido com um travesseiro forçando seu rosto para baixo. Como Dulce gritava que iriam matar o marido, um vizinho a ouviu, acionando a Polícia. Enquanto isso, os autores se apoderaram dos bens supracitados e, ao perceberem que tinham sido descobertos, conseguiram se evadir, levando consigo o produto do crime. Após a realização de exame pericial papiloscópico, foram localizadas as impressões digitais dos denunciados, indicando terem sido os autores do crime. A vítima Ademir Borges de Freitas, em juízo, confirmou as informações da exordial, afirmando que não consegue descrever os roubadores, pois estava escuro e levou um soco destes, caindo e batendo a cabeça. Por isso, também não conseguiu efetuar o reconhecimento dos réus. No dia dos fatos, estava dormindo, quando escutou os gritos de sua sogra e foi acudi-la. Quando estava no corredor, levou um soco no peito, caiu e bateu a cabeça, sendo colocado no sofá junto com sua sogra, sendo mantido com um travesseiro no rosto. Não conseguiu ver o rosto dos criminosos. Não viu ninguém armado. Foi feita perícia em sua casa, a qual acompanhou. Da mesma forma, a ofendida Dulce Baird de Freitas, narrando que não consegue descrever os roubadores, pois estes colocaram a mão em seu rosto. Em que pese não ter certeza absoluta, efetuou o reconhecimento dos réus YGOR e EDER, visto que tiveram gravações em sua residência e se assemelhavam as compleições físicas. No dia dos fatos, estava deitada, quando escutou um barulho muito grande, acreditando ser sua mãe, idosa e com problemas de saúde, que teria caído da cama. Assim que saiu correndo de seu quarto, em um corredor, deu de cara com um dos assaltantes - pessoa alta, estava muito escuro, o qual lhe jogou no chão, gritando por socorro para seu marido. Outro assaltante já estava com sua mãe - deste, não consegue lembrar. Quando seu marido veio, um terceiro roubadador também jogou seu marido no chão. Seu marido e sua mãe foram colocados na sala de TV, sendo ela levada para um quarto, onde ficou agachada na ponta da cama com um dos assaltantes por trás dela tampando seus olhos, empunhando arma de fogo e falando que queria dinheiro, joias, onde estava o cofre, falando que ia matar todo mundo e mandando ela calar a boca. Depois eles foram embora. Roubaram joias, seu celular, seu Ipad. De seu marido, foi levado o celular. A ação durou cerca de 20 minutos. Não viu a arma, mas sentiu ela quando um dos réus encostou algo gelado em sua pele. Teve sérios problemas de saúde em razão do roubo. Foi feita perícia em sua casa, inclusive diversas digitais. No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Willians Alves Berloff, que afirmou que no dia dos fatos acordou após ouvir um barulho na casa de seu vizinho e, como era de madrugada, ouviu nitidamente a frase "para com isso senão você vai matá-lo". Assim, pensou ser uma desavença familiar, ligando para o 190. Após, saiu para frente de sua casa para aguardar a viatura, sendo surpreendido com a passagem de um rapaz, que o questionou se havia visto duas moças subindo a rua, o que chamou sua atenção, pois o local é apenas residencial. Do jardim de sua casa, devido a ótima iluminação do local, viu o imóvel de Ademir e avistou a saída de alguns indivíduos estranhos pela sacada

existente no local, percebendo que estava acontecendo era um assalto. Logo após, os roubadores pularam para sua casa, ligando novamente para o COPOM e informou os novos fatos. Logo após chegou a viatura e saíram seus vizinhos narrando o roubo ocorrido. As imagens da ocorrência haviam sido gravadas pela câmera de monitoramento do local. Depois, os policiais detiveram dois dos possíveis roubadores, tendo identificado um deles pelas características físicas e outro pela vestimenta. Viu que foi feita perícia na casa da vítima, sendo coletadas impressões digitais, sendo o local preservado, pois as vítimas não ficaram no local, visto que ficaram muito abaladas. Eram cinco roubadores no total que estavam dentro da casa, mas acredita que havia um sexto que estava como "olheiro" do lado de fora. Eram todos jovens, com bermuda e camiseta. As palavras das vítimas e das testemunhas merecem total confiabilidade, já que não há qualquer razão plausível para que houvesse a incriminação gratuita dos réus, já que não se conheciam anteriormente e nenhuma animosidade havia entre eles. Os policiais militares Antônio Carlos Clemente e Miralva Vargues Teixeira ouvidos em juízo, corroboraram as declarações prestadas na fase policial, narrando que no dia dos fatos, foram acionados pelo COPOM para atender a ocorrência de roubo a residência envolvendo cinco indivíduos, mas já não havia mais ninguém no local. Efetuaram patrulhamento pela região, quando se deparam com dois indivíduos, Wellington e João Victor, na rua de cima da casa das vítimas. Esses indivíduos não confessaram o crime, mas as vítimas os reconheceram pelo que soube. Perto da casa foi achada uma caixa com algumas bijuterias. Em Juízo, ao serem interrogados, os réus negaram a prática do delito. No entanto, suas versões não encontram nenhum respaldo nos elementos de prova trazidos aos autos, pois não souberam explicar como suas impressões digitais puderam ser encontradas por peritos no local dos fatos, já que alegam nunca ter estado na residência das vítimas. Com efeito, há prova de autoria e materialidade suficiente para condená-los, já que o laudo pericial papiloscópico de fls. 292/309 comprovou que, na casa das vítimas, foram encontrados fragmentos de impressões papilares de YGOR, HUGO e EDER. Ou seja, no caso específico do acusado HUGO, suas impressões digitais foram localizadas no interior da casa invadida pelos autores, mais precisamente em uma lata vazia (porta trecos) "Coca-Cola". No tocante aos corréus YGOR e EDER, da mesma forma, foram encontradas impressões no parapeito da sacada, no lado externo do vidro da janela da sacada e no lado externo do vidro da porta da sacada. Ressalta-se que, conforme amplamente demonstrado pela prova dos autos, em especial pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, além dos laudos periciais do local dos fatos e o papiloscópico de fls. 240/245 e 292/309, o concurso de agentes estão presente nos fatos ora apurados, assim como o emprego de arma de fogo. Ainda, cabe ressaltar que a, mediante uma só ação, os réus praticaram dois crimes, subtraindo pertences de vítimas distintas, motivo pelo qual deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo qualificado. Destarte, satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal, a fim de que YGOR ALEXANDRE JAGER MESSIAS, HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA BUENO e EDER MATEUS GOMES MOREIRA sejam CONDENADOS nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, deve ser considerado

o dolo intenso dos réus em suas condutas, os quais, juntamente com seus comparsas, agrediram fisicamente as vítimas, bem como as consequências que o delito causou a essas, que restaram traumatizadas e tiveram as vidas para sempre alteradas - vide Dulce, que, mesmo após 3 anos dos fatos, chorou em juízo e afirmou que teve sérios problemas de saúde em razão do roubo -, pois sua casa foi invadida, mesmo considerada pela Constituição Federal como asilo inviolável. Além disso, devem ser consideradas as anotações criminais dos réus em datas posteriores à do delito em tela (cf. fls. 489/495), espelhando suas personalidades voltadas para a prática de crimes. Na segunda fase, deve ser considerada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", visto que a vítima Ademir possuía 72 anos na época dos fatos (fls. 09 16/20 e 481). Na terceira, deve incidir o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, bem como o concurso formal de crimes. No que tange ao regime, tem-se que o único compatível com a conduta dos acusados é o fechado. Trata-se de infração penal extremamente grave e de incidência massiva, que vem causando

reiterado desassossego na sociedade. Não é possível a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I e III do Código Penal, porque o delito imputado aos acusados foi praticado mediante emprego de violência e grave ameaça, conforme já exposto. Por fim, ausentes elementos seguros da capacidade econômica dos acusados, deve a multa ser fixada no patamar mínimo legal. Pela defesa do réu Eder foi alegado, em síntese: Imperioso reconhecer, na espécie, que, ao cabo da instrução processual, o respeitável Órgão Acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude do que a absolvição do acusado EDER é medida de rigor. Preliminarmente, tem-se que a própria denúncia ao imputar ao crime de roubo ao acusado registra que “após a realização de exame pericial papiloscópico, foram localizadas as impressões digitais dos denunciados, indicando terem sido os autores do crime”. Há evidente dúvida na imputação e resta claro que ao longo da instrução nenhuma outra prova surgiu de modo a corroborar a autoria delitiva. Sucede que o âmago do caso, face à inexistência de qualquer outro elemento de conexão à pessoa do acusado, centra-se no valor atribuído à sua impressão digital. É cediço que a impressão digital não faz prova direta da participação do acusado no fato criminoso, devendo ser encarada apenas como indício que deverá ser conjugado com outros elementos de prova, pelo que aquela por si só, não faz prova dessa participação. Vejamos os demais elementos: o acusado ao ser interrogado negou a prática delitiva. O acusado também afirmou desconhecer a existência de digitais suas na residência da vítima. As vítimas ao serem ouvidas mais uma vez em Juízo não reconheceram o acusado como autor dos fatos. Ambos os policiais NÃO confirmaram a existência de perícia no local. A policial militar Miralva ao ser ouvida em Juízo, sequer se recordou se houve perícia no local e ao ser questionada se o local teria sido preservado, afirmou não saber dizer, acrescentando ainda que se tal fato ocorreu não foi sua equipe a responsável por preservar. O policial Antônio afirmou pouco se recordar acerca do presente caso. afirmou também não se recordar se houve perícia no local e disse que desconhecer qual viatura teria sido responsável por isolar o local. A instrução não logrou êxito em demonstrar ser o acusado o autor do roubo descrito na inicial, não bastando para isso os indícios de autoria apontados na inicial. A presunção de inocência não pode ser sepultada pela existência de prova técnica indiciária, a qual não indica por si só o cometimento do roubo, máxime no presente caso em que os policiais que atenderam a ocorrência sequer se recordaram da existência de perícia no local ou de preservação. Logo, diante da evidente dúvida acima delineada, insolúvel à vista do conjunto probatório carreado ao caderno processual, e considerando-se que é corolário lógico do estado de inocência a idéia segundo a qual à acusação incumbe a produção de prova segura e inequívoca de todos os elementos constituintes do tipo penal – o que não se verificou no caso sub examine –, o único caminho que resta ao nobre Julgador, em postura reveladora de respeito intransigente às garantias individuais fundamentais, é o da prolação de um decreto absolutório, com supedâneo no artigo 386, VII, do CPP, o que ora se requer. Subsidiariamente, requeiro o reconhecimento de crime único, uma vez que as vítimas não indicaram terem os réus ciência da propriedade individualizada dos bens. Caso seja necessário infligir penas, a defesa roga sejam elas estipuladas na base mínima. Caso não acolhido o pleito retro, pela fixação de regime aberto em caso de eventual necessidade de desconto da pena segregativa, com permissão de eventual apelo em liberdade, tendo em conta que não está presente nenhum requisito de cautelaridade a justificar constrição da liberdade nesta fase processual. Pela defesa do réu Ygor foi alegado, em síntese: YGOR ALEXANDRE JAGER MESSIAS, devidamente qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, através de seus advogados que estas subscrevem, vêm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS NA FORMA DE MEMORAIS, nas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas: Consta do Inquérito Policial que no dia 16 de dezembro de 2018 por volta das 03:00hrs o Acusado e os corréus na Rua Pedro, nº 546, São Paulo/SP, subtraíram para si mediante grave ameaça os bens das vítimas Ademir Borges Freitas e Dulce Baird de Freitas Posto isto, à luz do domus litis, o respeitável Representante do Ministério Público denunciou YGOR ALEXANDRE JAGER MESSIAS e os demais Acusados, por terem incorrido, em tese, por duas vezes no disposto nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal na

forma do artigo 70 do Código Penal. Ato contínuo, fora realizada audiência de instrução, debates e julgamentos, sendo ouvida todas as partes. É a síntese do necessário. DO DIREITO DA NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS Importante ainda observar que no próprio laudo consta expressamente que o local dos fatos NÃO ESTAVA PRESERVADO para realização da perícia, e foi feita em data posterior aos fatos. Salienta-se que a defesa não busca tirar o crédito da vítima, ou afirmar que o delito em tela não ocorreu, porém NÃO HÁ PROVA DA AUTORIA DO CRIME POR PARTE DO ACUSADO Ora, conforme dito inicialmente as impressões digitais supostamente localizadas na residência não fora colhidas na data dos fatos, mas sim em momento posterior e sem a preservação do local. Nos termos do artigo 6º, I, do Código de Processo Penal é dever da autoridade apuradora que tiver conhecimento de uma infração penal deverá “dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais” Tal fatos são para que justamente que a prova não seja contaminada, possibilitando a sua integridade. No caso, não houve isolamento do imóvel pela autoridade policial e não foi esclarecido se existiam registros fotográficos da janela periciada, pelo contrário somente foi apresentada uma suposta fotorgafia da própria impressão, sem poder se dizer ao certo se estava na janela ou não. Além disso, evidentemente que o morador do imóvel permaneceu nele residindo, sem a preservação até que os peritos comparecessem e coletassem as impressões para análise. Curiosamente, uma das impressões digitais colhidas correspondeu à do acusado, impressão digital que, aliás, a polícia já possuía em seu banco de dados antes mesmo da realização do exame. No caso, quebrou-se a cadeia de custódia da prova, definida no artigo 158-A, caput, do Código de Processo Penal, como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. O § 1º do mesmo dispositivo processual determina que “o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio”. Importante mencionar, ainda, que o artigo 158-C, § 2º, do Código de Processo Penal, proíbe a entrada em locais isolados e a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. É exatamente este o caso dos autos: a residência jamais foi isolada pela autoridade policial, de modo que os peritos realizaram a colheita dos vestígios dias após o crime, período no qual o ofendido continuou ali residindo. Infere-se, então, que desde o início a cadeia de custódia foi violada, sendo impossível garantir a integridade dos vestígios. Consequentemente, a prova pericial é nula, devendo ser desprezada. Isto posto, mostra-se evidente que a única “prova” produzida contra o Acusado foi exclusivamente feita durante a investigação, sem a possibilidade do contraditório e ampla defesa, e não é corroborada com as demais provas produzidas durante o contraditório judicial. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ocorre que no caso em análise a única prova produzida pautou-se em um exame pericial que não foi respeitado o mínimo de cuidado para realização, uma vez que, conforme amplamente exposto, foi realizado dias após os fatos e sem a devida preservação do local. No mais, no caso dos autos a vítima e a testemunha de acusação nada acrescentou, pois não puderam esclarecer o ocorrido ou a suposta autoria. Os autos não apresentam maiores afirmações sobre o caso, nem mesmo traz depoimentos de testemunhas que possam corroborar as palavras dos policiais militares no que tange ao aludido delito, assim, pendendo de prova concreta que demonstre a sua ocorrência. Data máxima vênia, a palavra dos policiais neste caso, diante de todas as falhas e contradições apresentadas deve ser levada com máxima cautela. Cabe repisar que os relatos oferecidos pelos policiais, contrariamente ao que ocorre com as testemunhas civis, não são dotados da necessária imparcialidade, na medida em que os milicianos tenderão, por certo, a corroborar as diligências (e a própria prisão) efetivadas na

fase extraprocessual, sendo naturalmente inclinados, portanto, a atestar a lisura das suas ações realizadas na fase investigativa. Mais que tudo, porém, dar-se valor probatório pleno ao relato exclusivo de policial, ainda com possibilidade de engano, ofende o devido processo legal do Estado Democrático de Direito, em que avulta a garantia do contraditório (RT 43/322). Aliás, é justamente por isto que se tem entendido que os depoimentos dos policiais, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem embasar uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a própria descoberta da verdade material. Aqui destacamos que, por mais que sempre temos na palavra dos policiais, quase uma constatação de veracidade, sabemos que corriqueiramente condutas policiais são praticadas sem justificativas lógicas e que algumas situações não são trazidas da forma que realmente aconteceram. E aqui não estamos imputando nenhuma conduta criminosa aos policiais, estamos apenas destacando condutas muito comum para quem milita na área penal. Desta forma é evidente que a defesa encontrou grande dificuldade na produção de provas em favor do Acusado, bem como que a única prova que puderam ser utilizadas foram aquelas produzidas durante a investigação de forma unilateral, e que não respeitaram o rito estabelecido pela lei, ou seja, se tornaram provas ilegais. As provas apresentadas durante a instrução mostram-se insuficientes para o decreto condenatório, não podendo pautar apenas em uma perícia que não foi realizada de forma técnica, com a devida preservação do local, bem como fora feita dias após os fatos, e com fatos que não puderam ser confirmados em audiência. Data máxima vênia, para iniciar a ação penal bastam indícios, mas, para condenar é necessária prova, não podendo valer-se de meras alegações. Excelências, suspeita, como é óbvio, não gera a certeza necessária, apta a autorizar a condenação, no caso providência temerária. O sistema penal, baseado na presunção de não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a condenação, ao contrário da absolvição, para a qual basta a dúvida, em consagração ao princípio do *in dubio pro reo*, estampado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ora, ao cabo da instrução processual, sob o crivo do contraditório, não foram trazidos outros elementos de provas necessários para compor o contexto delituoso com a certeza imprescindível ao decreto condenatório. As provas colhidas em contraditório se mostram inconsistentes e não são capazes de autorizar o desfecho condenatório, pois as vítimas nada falaram sobre a conduta do Acusado, sequer o policial conseguiu trazer aos autos maiores esclarecimentos, pois nada se lembrava. Diante de todo exposto, sem existir qualquer prova inequívoca de autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, tendo-se em vista a primazia do princípio do *In Dúbio Pro Reo*. Excelência, para a condenação criminal exige-se a certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito, sendo insuficiente provas pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, sendo que, no caso do processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa. Conforme ensina Guilherme Nucci, existe grande diferença entre indício e presunção, pois enquanto o primeiro “é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias”, a última “não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo” (Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10ª ed., p. 542 e 545). Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações ou a palavra das vítimas, porém o conjunto probatório coligido aos autos não é suficientemente seguro para uma condenação pelos fatos aqui descritos. Pelo contrário há fundadas dúvidas quanto a produção das provas de forma unilateral feitas pela autoridade apuradora, comprovadas de forma documental, e outras porque não foram reafirmadas perante o juízo. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que: “A condenação requer certeza, sub '*specie universalis*', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5ª Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005) Não há nos autos, portanto, qualquer elemento de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da imputação contida na

denúncia. Ora, resta evidente que não há provas seguras do ocorrido e que os fatos estão confusos, e havendo sérias dúvidas sobre sua participação no delito, não sendo sequer reconhecido pela vítima, há que prevalecer o princípio do "in dubio pro reo", a impor a sua absolvição. Inviável, diante deste frágil quadro probatório, um decreto condenatório em seu desfavor, impondo-se, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. DA DOSIMETRIA DA PENA Posto isto, por respeito ao princípio da dialeticidade, caso esta Colenda Câmara, ainda entenda pela condenação do crime previsto no artigo, o que não se espera, passa-se a dosimetria da pena. Da fixação da pena passe em seu mínimo legal No caso em tela a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal devem ser sopesadas favoravelmente aos Acusados, objetivando-se o exame: (i) da culpabilidade; (ii) dos antecedentes; (iii) da conduta social; (iv) da personalidade do agente; (v) dos motivos; (iv) das circunstâncias; (vii) das consequências do crime e, por fim, (viii) do comportamento da vítima Vejamos, da análise dos elementos carreados aos autos, não há nenhum elemento em desfavor dos Réus. Verifica-se, no entanto, que este colaborar ou com a instrução processual, apresentando justificativas e os esclarecimentos necessários ao regular prosseguimento do feito. Primeiro ponto que merece destaque é que o Acusado É PRIMÁRIO e possuidor de bons antecedentes, até a época dos fatos. Conforme jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de justiça a prática de atos infracionais não é apta a configurar maus antecedentes ou reincidência, para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal. Isso porque "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social" (HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATO INFRACIONAL CONSIDERADO COMO MAUS ANTECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO ELEITA DE 3/8. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 443, DO STJ. ILEGALIDADE. 3. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. O entendimento vigente nesta Corte Superior é o de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para a reincidência. 3. A presença de duas causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena em sua terceira fase acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto assim justifiquem, porém, na hipótese, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 3/8 apenas com base na sua quantidade, ou seja, utilizando apenas o critério matemático, o que evidencia fundamentação inidônea e configura constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base do paciente HAMILTON ao mínimo legal, bem como diminuir a fração de aumento pelas majorantes para 1/3, determinando que as instâncias ordinárias redimensionem a pena aplicada, nos termos deste julgado. (STJ - HC: 289098 SP 2014/0039254-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2014) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme o entendimento firmado no âmbito na Terceira Seção, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social. (...) 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, fim de afastar da primeira fase da

dosimetria a consideração das passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude como circunstância desfavorável, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena. (HC n. 623.117/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021) No mais, a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DUPLA VALORAÇÃO SOBRE O MESMO DELITO. BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 3/8 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE VÁRIAS MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE PELA ESTREITA VIA DO WRIT. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O pleito de desclassificação para o crime de roubo, na modalidade tentada, não pode ser analisado por este Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a irresignação do paciente não foi apreciada pelo Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, fato que impede a análise da impetração por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. . 3. O sopesamento da culpabilidade, considerando o crescente número de crimes contra o patrimônio, configura fundamentação abstrata, circunstância que, por não trazerem elementos concretos, não se prestam a sustentar validamente a citada circunstância judicial. 4. Resulta em bis in idem a avaliação negativa acerca da personalidade sobre as mesmas condenações transitadas em julgado já ponderadas como maus antecedentes e também como reincidência. 5. Em relação aos motivos, verifica-se que são próprios do crime de roubo, de modo que não representa fundamentação válida a exasperar a pena-base. 6. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Eg. Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, é de se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 7. O mero cálculo aritmético acerca da existência do número de majorantes quanto ao crime de roubo não permite a majoração em 3/8 (três oitavos), sendo indispensável motivação concreta, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 443/STJ. 8. Pedido de isenção ao pagamento das custas processuais não constitui, por si só, cerceamento à liberdade de locomoção, passível de correção, na via do habeas corpus. 9. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para redimensionar a pena. (STJ - HC: 185246 MG 2010/0171102-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016) DIREITO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ARGUMENTOS GENÉRICOS OU CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO PRÓPRIO TIPO PENAL. Não é possível a utilização de argumentos genéricos ou circunstâncias elementares do próprio tipo penal para o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito. Precedentes citados: HC 150.025-DF, DJe 1/8/2011, e HC 170.730-AC, DJe 10/10/2011. (HC 165.089-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16/10/2012). Sendo assim, sobre a culpabilidade, a investida ousada ao patrimônio alheio, expressa exatamente o tipo penal do crime de roubo. A periculosidade de ir contra o patrimônio alheio já está prevista como fazendo parte desse delito, bem como a caracterização da violência e grave ameaça a pessoa. No mais, é evidente que a prática deste delito para sua ocorrência é necessária que o agente se aproveite de algum momento de fraqueza da vítima, ou em via pública, dentro de um veículo, ou até mesmo de sua residência, para surpreendê-la sem ser visto. Quando avalia as consequências do crime, por sua vez, escora-se no impacto psicológico que o crime "evidentemente" teve na vítima, sem apresentar qualquer laudo que possa justificar esse impacto. Lembrando que, se a jurisprudência deste Tribunal tem sido no sentido de ser permitida a aplicação da

circunstância "personalidade do agente" sem a apresentação de laudo psicológico, porém o mesmo não é verdade quando se trata de aferir o impacto psicológico que um crime teria causado numa dada vítima. Com efeito, o simples fato de o delito ter sido prático no período noturno, ou sobre o valor do bem que teria sido subtraído não demonstra por si só "elevado dolo e especial audácia" ou que a personalidade do acusado seria "marcadamente comprometida". Caso fosse assim, o legislador teria previsto tais circunstâncias como hipóteses de exasperação da pena, o que não é o caso. Nesse sentido, é preciso notar que o legislador entende, por exemplo, que o roubo que envolva emprego de arma de fogo e concurso de agentes deve ser reprimido mais severamente; por outro lado, silenciou quanto ao roubo ocorrido em residências e no período noturno. Note-se, por exemplo, que, nos casos de furto, o legislador entendeu por bem criar majorante de pena em razão da prática do delito durante o repouso noturno. Ou seja, poderia tê-lo feito também com relação ao roubo. Se não o fez, é exatamente porque entende que estas circunstâncias são indiferentes, pois o que realmente demonstra a reprovabilidade da conduta é o embate direto com a vítima. Enfim, como mencionado, o que realmente torna a conduta reprovável é o próprio confronto e emprego de violência ou grave ameaça contra o ofendido - circunstâncias que, aliás, determinam a cominação de altas penas ao delito. Exatamente por isso, no caso em tela, a prática de lesões corporais leves contra os ofendidos é circunstância inerente ao próprio tipo penal ("violência"). Caso as lesões fossem graves ou resultassem morte, por exemplo, haveria incidência do artigo 157, § 3º, do Código Penal, e aplicação de penas ainda mais altas. Por outro lado, havendo prática de lesão corporal leve, há mera configuração do tipo do artigo 157, caput, do Código Penal, de modo que qualquer exasperação significa dupla punição (bis in idem), o que não pode ser admitido. Ou seja, não se trata de circunstância judicial, mas de fato inerente ao próprio crime de roubo, cujo objetivo é essencialmente a subtração patrimonial; no máximo, é circunstância a ser levada em consideração na terceira fase da dosimetria, quando a recuperação dos bens subtraídos implica configuração da tentativa. Portanto, não é possível realizar qualquer aumento nesse sentido, sob pena de dupla punição (bis in idem). No mais, conforme depoimento prestados pelas vítimas os Acusados não agrediram, violentaram fisicamente ou verbalmente, não tendo qualquer conduta além daquela já prevista no tipo penal. Dessa forma, também em respeito ao princípio da individualização das penas deverá ser levado em consideração que os Acusados na realidade não agrediram as vítimas, fisicamente ou verbalmente, não praticando qualquer ato que não seja normal da espécie. Verifica-se ainda que do próprio boletim de ocorrência que as vítimas relataram que NENHUMA DELAS FOI AGRADIDA FÍSICAMENTE. Ora, Nobre Julgadora, não há qualquer prova nos autos que demonstre que a conduta dos Acusados mereça alto grau de reprovação, pois nada ultrapassaram do próprio tipo penal, e a vítima afirmou que não ocorreu nenhuma agressão, nenhuma violência física ou verbal. Não podendo desta forma alegar que a conduta do Acusado foi muito acima daquelas já previstas no próprio tipo penal DIREITO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ARGUMENTOS GENÉRICOS OU CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO PRÓPRIO TIPO PENAL. Não é possível a utilização de argumentos genéricos ou circunstâncias elementares do próprio tipo penal para o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito. Precedentes citados: HC 150.025-DF, DJe 1/8/2011, e HC 170.730-AC, DJe 10/10/2011. (HC 165.089-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16/10/2012). Da análise dos elementos carreados aos autos, não há nenhum elemento em desfavor dos Acusados, a personalidade deste não pode ser considerada como "voltada para a prática de crimes", primeiramente porque não há nos autos elementos suficientes para se referir a personalidade destes, e de outro lado a personalidade do agente não é conceito jurídico, mas afeto a outras áreas do conhecimento, sendo características individuais próprias que determinam ou influenciam o comportamento do indivíduo. Ora, não há no caso em tela qualquer elemento objetivo, a condutas do Réu não merece alto grau de reprovação, na medida em que não ultrapassou os atos próprios necessários do tipo, e quanto a sua conduta social e a sua personalidade nada foi apurado, devendo ser levado em consideração que o réu não é reincidente e não possui Maus antecedentes, razão pela qual a defesa pugna pela aplicação da pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Da ocorrência de

agravantes e atenuantes No caso dos autos deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa,

uma vez que o Acusado é menor de 21 anos na época dos fatos Diante o exposto, deverá ser aplicada a Atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal , mantendo-se as penas inalteradas nesta fase. Da ocorrência de causas de aumento e de diminuição da pena

Da necessidade do afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo Devemos destacar que a suposta arma de fogo utilizada no roubo nunca fora apreendida e sequer periciada, afim de comprovar a real utilização e sua potencialidade lesiva. Sem a apreensão e subsequente perícia do instrumento, é impossível o reconhecimento da majorante em questão. Para caracterização da potencialidade lesiva da arma, e assim, a aplicação da majorante prevista no artigo 157, §2º, I do Código Penal, mostra-se essencial a realização de perícia técnica afim de comprovar de que esta estaria apta para uso, ou até que não se tratava de arma de brinquedo. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de apreensão da arma de fogo para a implementação da causa de aumento de pena do inciso I, do § 2.º, do art. 157, do Código Penal, tem a mesma raiz exegética presente na revogação da Súmula n. 174, deste Sodalício. 2. Sem a apreensão e perícia na arma, não há como se apurar a sua lesividade e, portanto, o maior risco para o bem jurídico integridade física. 3. Ausentes a apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo, não deve incidir a causa de aumento. 4. Ordem concedida. (HC 59350/SP Rel p/ acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura T6 - SEXTA TURMA, DJ 28.05.2007 p. 402). Apesar de questionadas durante seu depoimento em audiência nenhuma vítima soube sequer esclarecer qual arma teria sido utilizada, e sequer trouxe elementos suficientes para se comprovar que esta realmente era de verdade ou estaria municiada estando apta para uso. Nobres Julgadores, se as próprias vítimas não esclareceram que acreditavam que a arma era de verdade, não pode-se presumir que de fato fora utilizada. Ora, poderia ter sido uma arma de brinquedo, conforme informado no depoimento do Acusado José, ou até mesmo estarem sem munição. No caso em tela, conforme já dito, não há qualquer prova no sentido da utilização da arma de fogo para realização do crime de roubo em tela, apenas a versão da vítima que nada trouxe com relação a sua aptidão para uso, não sendo esta suficiente para aplicação da majorante, devendo esta ser afastada. Da aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal Cumpre inicialmente registrar que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que: No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. A juíza de primeiro grau apenas fundamentou na sentença que: “aplico o índice exasperador de 3/8 (três oitavos), devido à presença das majorantes da comparsaria e da restrição de liberdade das vítimas e, ao depois, aplico o índice exasperador de 2/3 (dois terços), devido à majorante do emprego de arma de fogo” Posto isto, registra-se que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento dependem de fundamentação específica, com referência à gravidade do crime no caso em concreto, sendo este o entendimento disposto na Súmula 443 deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar esta matéria, afirmou a possibilidade de cumulação das causas de aumento, mas possibilitando a exclusão daquelas que houver sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado. O Ilustríssimo Ministro Gilmar Mendes em seu voto no julgamento ARE 896843 afirmou que: O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado. Diante disso, mostra-se necessário no caso em tela, que na terceira fase da dosimetria, caso esta Colenda Câmara não afaste a causa de aumento pelo uso de arma de fogo e/ou de restrição de liberdade das vítimas, seja

apenas aplicada uma delas, a de maior aumento, qual seja 2/3, aplicando-se apenas o previsto no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, a pena final seria de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses . Crime único A causa de aumento relacionada ao concurso formal não restou comprovada, pois se trata de um crime único, uma vez que os agentes não poderiam individualizar os bens de cada vítima, em se tratando de um roubo à residência, sendo as vítimas um casal. Nobres Julgadores, é evidente nos autos que trata-se de uma única casa, sendo que a as vítimas são uma entidade familiar, não havendo os indivíduos qualquer condição de identificar no momento do roubo se os pertences eram de uma ou de outra vítima. Isso porque não se identifica desígnios autônomos na subtração dos bens distribuídos pelo espaço da residência, embora mais de uma pessoa tenha sido ameaçada, não havendo como inferir o conhecimento dos agentes relativamente à propriedade dos pertences. Ademais, o entendimento o Tribunal de origem: Por fim, em razão do concurso formal, já que atingidos seis patrimônios diversos, a pena foi acrescida em ½ (metade), tornando-se agora definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. , não corresponde ao posicionamento desta Corte, conforme se verifica do seguinte julgado: 4. O delito de roubo praticado contra os bens protegidos em uma residência, quando não comprovada a existência de prévia e deliberada intenção de subtração de patrimônios distintos, independente da quantidade de pessoas vitimadas ou ainda de quem se encontre no exercício da posse ou detenção dos bens, caracteriza crime único, não prevalecendo, nessa hipótese, o número de patrimônios atingidos. O momento adequado para a valoração desse contexto é na primeira fase da dosimetria, devendo o juiz fixar uma pena-base ajustada ao caso concreto, avaliando, à luz do art. 59 do Código Penal, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, exasperando a reprimenda, se for o caso. (...) (HC 201.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, II E V, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TERCEIRA FASE. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO: NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA. IRRELEVÂNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA). IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA N. 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena-base se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. A Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Afastar o entendimento adotado pela instância de origem, no tocante à incidência da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, fatalmente obrigaria o revolvimento fático-probatório, providência incompatível com este átrio processual. 4. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante. 5. "O delito de roubo praticado contra os bens protegidos em uma residência, quando não comprovada a existência de prévia e deliberada intenção de subtração de patrimônios distintos, independente da quantidade de pessoas vitimadas ou ainda de quem se encontre no exercício da posse ou detenção dos bens, caracteriza crime único, não prevalecendo, nessa hipótese, o número de patrimônios atingidos. O momento adequado para a valoração desse contexto é na primeira fase da dosimetria,

devendo o juiz fixar uma pena-base ajustada ao caso concreto, avaliando, à luz do art. 59 do Código Penal, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, exasperando a reprimenda, se for o caso" (HC 201.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). 6. Concluído pelas instâncias de origem, com arrimo nos fatos da causa, que a paciente se dedicava às atividades criminosas, não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do